

1505271-15.2021.8.26.0022

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fernando Leonardi Campanella

Comarca: Amparo

Foro: Foro de Amparo

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 10/05/2022

... que acena para a prática do crime de tráfico de drogas pelo acusado. Vejamos.

Segundo se observa, os atuantes policiais estavam em patrulhamento rotineiro, quando avistaram o adolescente Ricardo, saindo de um "beco" próximo a conhecido ponto de tráfico daquele bairro, com algo na mão, demonstrando certo nervosismo ao avistar a viatura.

Assim, diante daquele contexto ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Amparo

Foro de Amparo

1ª Vara

Praça Tenente José Ferraz de Oliveira, 55, Amparo-SP - cep 13900-900

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1505271-15.2021.8.26.0022 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1505271-15.2021.8.26.0022

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2285503/2021 - DEL.POL.PLANTÃO AMPARO, 20913074 - DEL.POL.PLANTÃO AMPARO, 1488/21/935 - DEL.POL.PLANTÃO AMPARO, 2285503 - DEL.POL.PLANTÃO AMPARO

Autor:

Justiça Pública

Réu e Indiciado:

TALYS AUGUSTO DE ANGELI e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz de Direito: Fernando Leonardi Campanella

VISTOS.

TALYS AUGUSTO DE ANGELI, qualificado nos autos (fl. 25), foi denunciado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, como incurso no artigo 33, caput, cc.

art. 40, VI, ambos da Lei nº 11.343/06, acusado de ter, no dia 19 de outubro de 2021, por volta das 13h45min, na Rua Roraima, 65, Casa 05, Jardim Brasil, nesse Município e Comarca de Amparo, transportado, por intermédio do adolescente Ricardo de Angeli Portugal, para fins de fornecimento ao consumo de terceiro, 01 (uma) porção de cocaína, pesando aproximadamente 0,6g, e sido surpreendido mantendo em depósito em sua residência, para fins de fornecimento ao consumo de terceiros, 11 (onze) porções de cocaína, embaladas individualmente, pesando 7,6g e 05 (cinco) porções de "maconha", pesando 51g, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (fls. 140/142).

Prisão flagrancial convertida em preventiva (fls. 50/54).

A denúncia foi recebida em 19.11.2021 (fl. 146).

O réu foi regularmente citado (fl. 227) e, por intermédio de sua D. Defensora nomeada apresentou resposta por escrito à imputação (fls. 223/224), arrolando as mesmas testemunhas do rol acusatório.

Não sendo o caso de julgamento in limine, com absolvição sumária do acusado, determinou-se a abertura de instrução probatória (fls. 236/237), ocasião em que foi colhida a prova oral, consistente nas oitivas das três testemunhas arroladas em comum, seguindo-se do interrogatório do acusado, tudo pelo sistema audiovisual (cf. atas de fls. 257 e 265).

Em sede de memoriais escritos, a D. Promotora de Justiça requereu a condenação do réu nos exatos termos da denúncia, por entender suficientemente provado autoria e materialidade delitiva (fls. 268/274). A D. Defensora, por sua vez, requereu a absolvição sustentando inexistirem provas seguras para o decreto condenatório. Subsidiariamente, pugnou pelo afastamento da causa de aumento e teceu considerações a respeito da pena e do regime prisional (fls. 278/284).

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A pretensão punitiva procede.

A materialidade da infração está devidamente comprovada por meio dos autos de exibição e apreensão (fls. 19/20), constatação provisória (fl. 21/22 e 23/24), ilustrados com fotos (fls. 42, 43 e 44), bem como e, principalmente, pelos laudos do exames químico-toxicológicos realizados nas substâncias entorpecentes (fls. 190/191, 192/194 e 195/197).

Com efeito, os laudos confirmaram tratar-se de cocaína e "maconha", neste ultimo caso destacando a presença do Tetrahydrocannabinol (THC), substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, listadas na Portaria nº 344/98 - SVS/MS.

Por fim, há o laudo dos exames periciais realizadas na balança digital (fls. 198/200), no saco contendo bexigas e na fita adesiva (fls. 201/203), apetrechos normalmente utilizados para a embalagem e acondicionamento de drogas.

A autoria, da mesma forma, é inconteste.

Vale lembrar, em primeiro lugar, que TALYS foi preso em flagrante, após ter se valido do irmão inimputável, o adolescente Ricardo, para transportar drogas, além de, num momento seguinte, vir a ser surpreendido mantendo em depósito em seu quarto, mais entorpecentes, cuja semelhança, quantidade e forma de acondicionamento, além das circunstâncias fáticas, indicam destinação ao tráfico ilícito, razão pela qual a autoria torna-se certa, pois, segundo Rafael Magalhães,

apud Tourinho Filho, a prisão em flagrante "é a certeza visual do crime". A expressão também é usada na doutrina clássica por Tostes Malta, na obra "Do Flagrante Delito", 1933, p. 25.

De acordo com Hélio Tornaghi, prender em flagrante é capturar alguém no momento em que comete um crime. Ainda segundo o ilustre autor: "Nunca é demais lembrar que a flagrância talvez seja a prova mais eloquente do crime e da respectiva autoria" ("Curso de Processo Penal", 5ª ed., 49).

Ademais, a análise coligida dos depoimentos colhidos no caderno investigativo e produzidos na fase judicial autoriza concluir pela responsabilidade penal do agente. Vejamos.

Segundo se depreende dos depoimentos dos policiais ouvidos em juízo, Cristiano e Estevão, eles estavam em patrulhamento de rotina, quando, ao passarem por conhecido "ponto" de tráfico do Jardim Brasil, na Rua Roraima, avistaram o adolescente Ricardo saindo de um "beco" com algo nas mãos, tendo ele, ao notado a presença da viatura, demonstrado certo nervosismo "apertando o passo" (sic), o que gerou fundada suspeita. Abordado, foi localizado em sua mão uma porção de cocaína. Indagado, ele disse ter recebido aquela droga do acusado TALYS, seu irmão, para que a entregasse a um indivíduo gordo, que viria em uma moto prata, que pagaria R\$50,00. O réu foi localizado nas imediações, em um bar, e confirmou a versão do adolescente, salientando haver mais drogas dentro de casa. Franqueado ingresso no imóvel pelo próprio réu, foi ele também quem indicou onde estavam, dentro de uma bolsa, as 05 porções grandes de "maconha" e 11 porções de cocaína, além de uma balança digital, bexigas e fita adesiva. Questionado sobre estes entorpecentes, o réu confessou que os venderia. Nas dependências da Delegacia de Polícia, acompanhado da genitora, o adolescente Ricardo confirmou seu relato e ainda destacou que as drogas eram entregues ao seu irmão para funcionamento e comercialização, por "Mineiro", conhecido nos "meios" policiais por ser gerente da "biqueira" daquele bairro.

O adolescente Ricardo de Angeli Portugal, diversamente do relatado em solo policial, quando, na presença de sua genitora, confirmou ter recebido do acusado, seu irmão, aquela porção de cocaína para que fosse entregue a um indivíduo "gordinho de moto", quando foi abordado pelos policiais em poder daquele entorpecente e lhes relatou todo o contexto, delatando TALYS, que veio a ser abordado (fls. 07/08), em juízo modificou substancialmente sua versão, certamente para beneficiar o irmão. Disse, nessa nova ocasião, que estava com a droga na mão, quando veio a ser abordado pelos policiais. Questionado, relatou ter descoberto que seu irmão guardava droga e, então, pegou, escondido, aquela porção de cocaína para vender. Negou que seu irmão tivesse lhe pedido para entregá-la para um indivíduo de moto.

O réu, ao tempo do seu interrogatório no auto de prisão em flagrante, alegou ter sido abordado pelos policiais, que já conduziam seu irmão Ricardo. Foi indagado a respeito da existência de drogas dentro do imóvel, confirmando prontamente, mas salientando serem para seu consumo pessoal, eis que viciado. Negou ter entregue uma porção de cocaína ao seu irmão para que ele a vendesse em seu nome, tendo descoberto que ele a retirou, sem o seu conhecimento, do local em que estavam escondidas, somente no momento em que as 11 porções foram encontradas pelos policiais (fl. 11).

Em juízo, TALYS voltou a negar a prática delitiva. Alegou que estava em um bar e avistou quando os policiais abordaram seu irmão, motivo pelo qual deles se aproximou. Veio a saber que Ricardo estava com um pino de cocaína, mas não era do conhecimento do interrogando aquela situação. Negou que tivesse entregue ou pedido para que seu irmão vendesse droga. Não soube informar porque Ricardo inventou aquela história para os policiais. Os entorpecentes localizados dentro da sua

residência lhe pertenciam e se destinavam ao seu consumo pessoal. Adquiria drogas à granel e as fracionava e acondicionava, por ser "mais barato".

Pois bem. Este é o contexto probatório que acena para a prática do crime de tráfico de drogas pelo acusado. Vejamos.

Segundo se observa, os atuantes policiais estavam em patrulhamento rotineiro, quando avistaram o adolescente Ricardo, saindo de um "beco" próximo a conhecido ponto de tráfico daquele bairro, com algo na mão, demonstrando certo nervosismo ao avistar a viatura.

Assim, diante daquele contexto fático e da reação comportamental incomum, geradora de fundadas suspeitas, houve sua abordagem, ocasião em que foi localizada em uma das mãos, uma porção de cocaína. Questionado, de pronto, Ricardo já lhes relatou tê-la recebido do seu irmão, ora acusado, para que entregasse a um indivíduo, de compleição física mais avantajada, que aparecia em uma moto de cor prata para pegá-la, pagando R\$50,00.

Ato contínuo, os policiais passaram a diligenciar e identificaram TALYS nas imediações, próximo a um bar existente. Indagado sobre a delação do irmão, o réu confessou informalmente os fatos e ainda confirmou ter mais entorpecentes dentro do imóvel, sendo que além de franquear-lhes a entrada, ainda indicou o exato local em que estava a bolsa contendo mais 11 porções de cocaína, idênticas aquela encontrada com o adolescente ao tempo da abordagem inicial, bem como 05 porções de "maconha", balança digital, bexigas e fita adesiva.

Incontroverso que os entorpecentes pertenciam ao réu.

Outrossim, não haveria razão para que Ricardo, abordado em poder de apenas 01 porção de cocaína, podendo dizer aos policiais, diante daquela pequena quantidade e sem estar em poder de valor em dinheiro, se tratar de droga para consumo pessoal, delatar o irmão com detalhes tão precisos como a entrega, a pedido de TALYS, daquela porção para um indivíduo "gordinho", que viria em uma moto na cor prata e pela qual pagaria R\$50,00.

E tal versão foi verbalizada por Ricardo ao tempo da sua abordagem pelos policiais militares, situação por eles confirmada em seus depoimentos prestados sob o crivo do contraditório, bem como documentada pelo termo da sua oitiva em solo policial, na presença de sua genitora (cf. 07).

Somente depois, vendo o efeito danoso daquela delação e a permanência do irmão em estabelecimento prisional é que, sob o crivo do contraditório, Ricardo, ouvido como informante, alterou sua versão visando atrair para si a responsabilidade exclusiva e, conseqüentemente, inocentar o réu.

Como é sabido, frente à comum disposição de inocentar, determinadas pessoas, com certa vinculação ao réu, podem ser ouvidas em juízo, mas sem o compromisso de dizer a verdade, tal como preceitua o art. 206 do CPP, devendo seus relatos serem recebidos com reservas e serem ponderados à luz dos demais elementos probatórios existentes nos autos.

Não havia razões para que Ricardo apontasse, primeiro aos policiais militares e, depois, na Delegacia, TALYS como a pessoa que lhe entregou aquela porção de cocaína apreendida em seu poder para que a vendesse àquele indivíduo, sob determinadas condições, caso não fosse a mais fiel retratação do cenário fático visto para o momento.

Inexistem razões para os policiais inventarem tal história.

E não é só.

As fotografias de fls. 43 e 44 revelam a identidade entre a porção de cocaína apreendida em poder do adolescente (01) e aquelas mantidas em depósito pelo réu (11). Há, ainda, a fotografia de fl. 42 documentando as porções de "maconha", em tamanho incomum para simples usuários, que seriam alvo de fracionamento e acondicionamento, com o uso da balança digital, de bexigas e da fita adesiva, objetos também apreendidos.

Bem verdade que a prova oral colhida durante a instrução baseia-se, principalmente, no depoimento dos agentes que realizaram a investigação criminoso, mas, vem sendo pacificada a repulsa nas Egrégias Cortes, com lastro do maior quilate na Superior Instância e na Extraordinária em especial, quanto à alegação de imprestabilidade dos depoimentos daqueles que participam da diligência que culmina com a apreensão do entorpecente.

Tal insistência visa ressuscitar uma velharia nociva prejudicial, destinada a neutralizar o esforço até patriótico na luta contra as drogas, em recalcitrar, atribuindo-se ao Estado, a desinteligência de conferir a tais agentes o encargo importantíssimo de coibir o crime, mas, lhes recusar credibilidade para testemunhar.

Ademais, não se provou, nem se invocou com concretude, algo em que se baseasse alguma das hipóteses de válido repúdio a ditos testemunhos, a inverosimilhança ou o entrechoque com outras provas.

Assim, concluo serem válidos e plenamente eficazes os depoimentos ofertados pelos policiais que efetuaram o diligenciamento criminoso, haja vista não contarmos com informações que desabonem ou desprestigiem suas condutas e formas de atuação, tampouco para que atribuísem ao réu os fatos, incriminando-o maliciosa ou levianamente, até porque nem mesmo o conheciam dos "meios" policiais.

A versão do réu não convence, seja porque não havia motivos plausíveis para que seu irmão o delatasse falsamente – deixou claro em seu interrogatório reunir bom relacionamento junto aquele, seja porque dentro do seu imóvel foram encontradas mais drogas, de natureza diversificada, cuja quantidade e forma de acondicionamento, agregado aos apetrechos, indicam destinação mercantil.

Nesse contexto, a negativa do réu não se sustenta.

Outrossim, inexistem elementos indicativos de ser ele mero usuário e de que aqueles entorpecentes, naquelas circunstâncias fáticas e forma de acondicionamento, se destinavam exclusivamente ao seu consumo pessoal.

Como também reconhecem os tribunais:

"Não cabe a desclassificação do delito de tráfico ilícito de substância entorpecente, para o delito de uso indevido, quando ausente a prova, a cargo da defesa, da exclusividade do uso próprio." (RT 710/325).

Destarte, ante a valoração dos elementos fáticos probatórios, inviável o pedido de absolvição do réu, eis que os argumentos lançados são frágeis, sobretudo diante do contexto criminoso em que estava inserido.

Nesse passo, anoto que as condutas de transportar e manter em depósito não afastam a violação ao art. 33, da Lei nº 11.343/2006, pois, para a consumação do crime prescinde de atos de comercialização, porque se trata de dispositivo de conteúdo variado, ou de ação múltipla, ensejando a prática do delito, em questão, a violação a qualquer uma das suas várias condutas.

É evidente que o tráfico de entorpecente envolve atividades essencialmente

clandestinas, daí a razão da não exigência da prova flagrancial do comércio ilícito, mas elementos, concretos, que forneçam a evidência do comércio.

Outrossim, já se decidiu que “para a formação do juízo de certeza razoável sobre o comércio de drogas de agente devidamente processado, não é indispensável à prova efetiva do tráfico. Tal convencimento pode resultar satisfatoriamente comprovado pelo conjunto de indícios e circunstâncias que cercam o agente...”.

Frise-se, ainda, já se decidiu que, “para se identificar o traficante e distingui-lo do usuário, não é só o problema da quantidade que se deve levar em conta. Os próprios traficantes raramente são encontrados com grandes quantias de tóxicos, pois se de um lado não pretendem correr o risco de perder tudo, numa investida policial, ou de outro a pequena quantidade pode prestar-se a vendas a varejo e mesmo a dissimulação do característico de mercancia” (Vicente Grecco Filho, in “Tóxicos”, 1993, Editora Saraiva, n. 17, pág. 120, destaquei).

Aliás, é sabido que a condição de usuário veiculada – sequer minimamente documentada, não exclui, a priori, por si só, a condição de traficante, somente se aplicando a desclassificação quando os elementos permitirem cabal aferição nesse sentido, o que não ocorreu na hipótese.

Sendo assim, as circunstâncias fáticas e a prova oral colhida se mostram suficientes para a condenação do réu pelo delito de tráfico de entorpecentes, não havendo campo para desclassificação (art. 28, caput, da Lei nº 11.343/06) – tese nem mesmo defendida em sede de memoriais, sob pena de se afrontar à prova dos autos e a boa atuação dos policiais.

Por fim, restou inconcussa a presença da causa de aumento prevista no art. 40, inciso VI, da Lei 11.343/06:

Art. 40. “As penas previstas nos arts. 33 a 37 desta Lei são aumentadas de um sexto a dois terços, se:

(...)

VI - sua prática envolver ou visar a atingir criança ou adolescente ou a quem tenha, por qualquer motivo, diminuída ou suprimida a capacidade de entendimento e determinação;

Envolver criança ou adolescente tem sentido de atuar conjuntamente, utilizar ou contar com a participação. É hipótese em que o agente atua em concurso eventual com criança ou adolescente, aliás, prática recorrente no ambiente do tráfico, notadamente em razão da menor capacidade de discernimento e resistência moral daqueles, a proporcionar maiores facilidades na cooptação, e da condição de inimputabilidade a que os mesmos personagens-alvo estão submetidos.

Buscou o legislador agravar a situação daquele que se utiliza dos “préstimos” de adolescente, disseminando droga em sua vida e atrelando-o ao comércio espúrio de entorpecente em detrimento de uma vida correta, pautada pelos estudos e trabalho honesto, mostrando a ele lucro fácil na tentativa de lhe desvirtuar do caminho que deve percorrer os cidadãos de bem.

O contexto probatório indica a relação do acusado com o adolescente Ricardo, a quem incumbiu transportar a droga até o usuário, vendendo aquela porção de cocaína pelo valor de R\$50,00.

O fato é típico, antijurídico e culpável, não havendo excludentes de ilicitude ou dirimentes de culpabilidade a ser reconhecida, razão pela qual a condenação e imposição da correspondente reprimenda estatal por este delito são medidas que se impõem.

PASSO À DOSAGEM DA PENA.

Atento às diretrizes previstas no artigo 59 do Código Penal, da análise de sua Certidão de Eventos (fls. 45 e 46) verifico que o réu é primário e não conta com antecedentes conhecidos. Da mesma forma, à luz do art. 42, da Lei de Drogas não evidencio a presença de circunstâncias judiciais desabonadoras, razão pela qual a pena-base poderá permanecer no mínimo legal.

Ausentes agravantes e/ou atenuantes.

Por fim, há a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, VI, da Lei de Drogas, razão pela qual, havendo apenas um adolescente envolvido, majoro a pena de 1/6 (um sexto). De outro canto, presente a causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, eis que presentes os pressupostos legais (ser o agente primário, detentor de bons antecedentes e não se dedicar a atividades criminosas ou integrar organização criminosa).

O referido dispositivo prevê a possibilidade do Juiz (leia-se: poder-dever) em reduzir de 1/6 a 2/3 a pena fixada quando presentes os quatro requisitos cumulativos acima elencados, sem, contudo, estabelecer parâmetros para o exato estabelecimento deste quantum pelo magistrado.

Nesse diapasão é que, no caso em exame há de ser levado em conta a natureza e quantidade da substância apreendida. Parece-me razoável asseverar que quanto maior a quantidade, mais variados os tipos e o campo de comercialização deles, menor a diminuição da pena.

É nesse sentido, inclusive, o posicionamento da 5ª Turma do C. STJ (HC 136.618/MG, Min. Laurita Vaz, v.u. 01.06.10) e da 5ª Câmara Criminal do E. TJSP (Ap.990.09.170.228-5 – Des. Rel. Marcos Zanuzzi, v.u. j. 10.12.09).

Nesta esteira, atento a quantidade e a natureza dos entorpecentes, com grande campo de comercialização e efeito danoso para a saúde, é que a redução deverá ser feita na proporção de ½ (metade).

No que tange ao regime penitenciário, a obrigatoriedade do regime inicial fechado para os condenados por crimes hediondos e os a ele equiparados foi declarada inconstitucional pelo Col. Pretório Excelso, em 27.6.2012, por ocasião do julgamento do HC 11.840/ES, no Pleno, rel. Min. Dias Toffi.

Assim, a identificação do regime inicial mais adequado à repressão e prevenção dos delitos deve observar os critérios do art. 33, §2º e 3º do Cód. Penal, bem como do art. 42 da Lei 1.343/2006, quando se tratar de delitos previstos nessa Lei (STJ HC 272.152/SP rel. Min. Marilza Maynard 6ª Turma J. 10.12.2013).

Mesmo conhecedor do recente posicionamento do C. STF exarado no HC 118.533 (23.06.16) decidindo não ser o “tráfico-privilegiado” de natureza assemelhada ao crime hediondo, é posicionamento deste julgador que o caso em apreço reclama a imposição de regime INICIAL FECHADO, até porque o réu desenvolvia atividade ilícita, valendo-se inclusive do próprio irmão, adolescente.

Cabe invocar ensinamento daquela mesma Corte Suprema: “A determinação do regime inicial de cumprimento da pena não depende apenas das regras do caput do art. 33 e seu parágrafo 2º do Cód. penal, mas, também, de suas próprias ressalvas, conjugadas com o caput do art. 59 e inciso III (RHC 64.970). E deve ser feita, nos termos do parágrafo 3º do art. 33, com observância dos critérios previstos no art. 59” .

Ora, é de pronta intelecção que a perpetração de tráfico denota personalidade inteiramente avessa aos preceitos ético-jurídicos que presidem à convivência

social. Tendo isso presente, deve o juiz sujeitar o agente ao mais severo regime prisional.

Acresce ponderar que a concessão de regime aberto ou semiaberto ao autor de tráfico ilícito de substância entorpecente desvitaliza a eficácia intimidante da pena, tornando-a inócua, mormente frente ao seu retorno precoce à sociedade, com a sensação de Justiça banalizada.

Lembro, por fim, que a imposição coletiva vinculante quanto à vedação de fixação do regime inicial fechado para cumprimento da pena imposta aos condenados pelo crime de tráfico na modalidade privilegiada, determinada pelo voto monocrático de lavra do E. Relator Ministro Rogério Schietti Cruz (6ªT do C. STJ) em sede de HC nº 596.603/SP, foi CASSADA pela r. decisão exarada pelo Exmo. Ministro do C. STF, Alexandre de Moraes, ao tempo do julgamento do RE nº 1.344.374, em 1º/12/2021, conferindo ao julgador a liberdade de avaliar o regime prisional cabível em cada caso.

NÃO há campo para aplicação do artigo 387, §2º, do CPP, devendo a progressão do regime ser analisada pelo juízo da execução, competente para tanto, na medida em que detém as informações necessárias, sob os prismas objetivo (cálculo de pena) e subjetivo (comportamento carcerário) para enfrentar a questão.

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal formulada na denúncia para CONDENAR o réu TALYS AUGUSTO DE ANGELI, qualificado nos autos, a cumprir pena de 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 290 (duzentos e noventa) dias-multa, cada qual no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo da data dos fatos, com correção monetária na fase executória, na forma do §2º do art. 49, por infração ao delito previsto no artigo 33, §4º, cc. art. 40, VI, ambos da Lei nº 11.343/2006.

INCABÍVEL a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Não se desconhece que em 01.09.2010 o Supremo Tribunal Federal, a mais alta corte do Poder Judiciário, decidiu pela inconstitucionalidade da vedação legal à substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos nos crimes regulados na Lei Federal nº 11.343/2006. O emblemático leading case coube ao "Habeas Corpus" nº 97.256, impetrado pela Defensoria Pública da União no município de Porto Alegre-RS.

Também não passa despercebido que o Senado Federal, recentemente, promulgou no dia 15 de fevereiro a Resolução nº 05 de 2012, suspendendo, nos termos do art. 52, inciso X, da Constituição Federal, a execução da expressão "vedada a conversão em penas restritivas de direitos" do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 (Lei de Drogas).

Todavia, salvo raríssimas e excepcionais situações, a condição de traficante inviabiliza o agraciamento do agente com a substituição em voga, pois o comercializador de drogas, desprovido de senso moral, destruidor de lares e famílias, não preenche os requisitos subjetivos estampados em lei.

O tráfico de drogas apresenta lucros incalculáveis e prejuízos incontáveis à ferida sociedade, tratando-se de mercancia vil, de intensa potencialidade lesiva para a saúde pública e para a sociedade.

Tal constatação vai de encontro com o requisito previsto pelo inciso III, do artigo 44, do Código Penal, exigido, cumulativamente a outros, qual seja, "os motivos e circunstâncias do crime indicarem que essa substituição seja suficiente".

Nesse sentido:

"Não parece razoável que o condenado por tráfico de entorpecentes, seja ele de pequeno, médio ou grande porte, seja beneficiado com essa substituição, porque, em todas as suas modalidades, trata-se de delito de extrema gravidade e causador de inúmeros males para a sociedade, desde a desestruturação familiar até o incentivo a diversos outros tipos de crimes gravíssimos, que, não raro, têm origem próxima ou remota no comércio ilegal de drogas, sem falar do problema de saúde pública em que já se transformou" (HC 203.403/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 5ªT, j. 21/06/2011, DJe 01/07/2011).

Aliás, bem ressaltou o Eminentíssimo Desembargador Ricardo Tucunduva, "...o tráfico de drogas é delito incompatível com tais benefícios, podendo o legislador, então impor maior rigor na sanção aplicada aos seus infratores, em prol dos interesses da população ordeira e trabalhadora de nosso país..." (TJSP - 6ª Câmara de Direito Criminal, Ap. nº 0000472-64.2011.8.26.0115, j. 02.02.12).

E, ainda, sobre a índole e personalidade de pessoas voltadas para o comércio ilícito de substância entorpecente atentemos-nos para o fato de que o "... traficante de entorpecente é indivíduo desprovido de sensibilidade ética-moral, guiando-se apenas pelo lucro fácil, arrastando para o mal milhares de jovens, contribuindo para a deterioração da saúde alheia, levando desespero e trauma aos familiares desses jovens. Lares são destruídos, sequelas enormes não somente nos jovens atingidos pelas garras desses impiedosos traficantes, como também a seus genitores .

Ademais, não nos parece ter sido a intenção precípua do Poder Constituinte Originário conceder beneplácitos a crimes equiparados aos hediondos, cujo tratamento jurídico merece maior rigorismo.

A meu sentir, respeitado judicioso entendimento em sentido contrário, seria ilógico substituir penas privativas de liberdade para impor sanções restritivas de direitos a condenados por crimes hediondos ou equiparados a eles, sob pena de se esvaziar o tratamento mais rígido que a Lei buscou imprimir, fortalecendo a política criminal voltada a inibir a mercancia espúria de estupefacientes, que, a propósito, propaga sempre outras práticas delitivas execráveis que tanto devastam o país, notadamente de índole patrimonial.

O réu permaneceu preso durante a instrução processual por força de decisão judicial fundamentada (fls. 52/54). E, presentes os requisitos e fundamentos da prisão preventiva, em especial à aplicação da lei e a garantia da ordem pública (art. 312, caput, cc. 313, ambos do CPP), agora, frente ao édito condenatório, com pena a ser cumprida em regime prisional mais gravoso, com maior razão, deverá aguardar presa a fase recursal (art. 387, §1º, CPP).

Recomende-se o réu no local em que estiver recolhido.

Autorizo a destruição das substâncias entorpecentes apreendidas que ainda não tenham sido incineradas, oficiando-se.

Custas na forma da lei.

Oportunamente, expeça-se carta de guia de execução (Súmula nº 716, do STF) e anote-se a condenação definitiva no Sistema Informativo Oficial, com as devidas comunicações ao IIRGD, nos termos do Provimento nº 33/2012, da E. Corregedoria Geral de Justiça (art. 372 das NSCGJ).

P.R.I.C.

Amparo, 10 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA